

1502581-04.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Viviane, como envolvimento com drogas e trafico. Na data em questão, Viviane não havia informado nada a respeito da mala encontrada. Informou que na época dos fatos Viviane havia saído há poucos meses da empresa em que ela trabalhava. (SAJ)

Da análise do conjunto probatório, reputo que a ré praticou o delito de tráfico de drogas.

Como se vê, a versão apresentada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502581-04.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502581-04.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213124/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 19478190 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 4813/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2213124 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2213124 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 4813/21/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Viviane Antunes Cardoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

VIVIANE ANTUNES CARDOSO, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 07 de agosto

de 2021, na Avenida 52-A, bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria mantido em depósito e, guardado, para fins de entrega a consumo de terceiros, 374 porções de cocaína em eppendorfs, com peso líquido de aproximadamente 297g, 4 porções de cocaína em papéletes, com peso líquido de aproximadamente 197g e 26 tijolos de maconha (tetrahydrocannabinol), com peso líquido de aproximadamente 21.149g.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/21), laudo de constatação (fls. 83/85) e exame químico-toxicológico (fls. 88/90).

A acusada Viviane foi notificada (fls. 118), apresentou resposta escrita (fls. 120/122) e a denúncia foi recebida (fls. 123/125).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. (SAJ)

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu a nulidade em decorrência da ilicitude da ação policial, enquanto no mérito requereu a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a preliminar de nulidade em razão da ilicitude da ação policial.

Dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Já o artigo 302 do Código de Processo Penal dispõe que: "Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração."

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão, possibilitando, ainda, a prisão em flagrante a qualquer momento.

Conforme demonstrado nos autos, os policiais militares, após receberem denúncia anônima informando que um veículo havia deixado uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência. Deslocaram-se até o endereço e avistaram Viviane na garagem da residência. Em contato com ela, esta confirmou que haviam deixado uma mala preta em sua residência, mas que não sabia a procedência nem o que havia em seu interior. Foi franqueada por ela a entrada na residência, ocasião em que foi localizada a mala preta contendo em seu interior os entorpecentes (cocaína e maconha) e apetrechos. Sendo assim, estavam amparados pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito.

A propósito do tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso

Extraordinário com Repercussão Geral e por maioria de votos que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE nº 603.616/R0, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, d.j. 05/11/2015).

No presente caso, a denúncia recebida, a confirmação da própria ré de que havia recebido uma mala e a posterior localização dos entorpecentes são elementos aptos a preencher os reclames da fundada suspeita, justificando-se a invasão de domicílio independentemente de mandado judicial.

Como se não bastasse, verifica-se pelo interrogatório prestado pela ré que ela confirmou ter franqueado a entrada dos policiais militares na residência.

Desse modo, foi constitucional e legal a conduta dos policiais militares ao adentrarem na residência mesmo sem estarem munidos de mandado judicial.

Nesse sentido:

“Apelação defensiva – Tráfico de entorpecente. Preliminar de nulidade – Invasão de domicílio – Delito permanente – Flagrante – Desnecessidade de mandado judicial de busca – Repercussão geral. Autoria e materialidade configuradas – Depoimentos dos agentes policiais em harmonia com as demais provas dos autos, ratificando a prova administrativa – Desclassificação para uso pessoal – Impossibilidade – Finalidade mercantil – Bases no mínimo – Confissão – Súmula 231 do STJ – Redução, em seguida, de 1/6, nos termos da minorante do § 4º do art. 33 da Lei Especial, resignada a acusação – Regime fechado – Impossibilidade de substituição por restritivas – Precedentes – Devolução do dinheiro apreendido – Viabilidade, no caso – Prova da origem – Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apelação nº 0041522-68.2014.8.26.0114, Campinas, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Ivan Sartori, d.j. 05/04/2016) – grifamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Condenação – Recurso defensivo – Preliminar de nulidade por invasão de domicílio – Afastada – Delito permanente, podendo-se prender os agentes a qualquer momento – Breve campana, visualizando, os policiais, o apelante em ato de comércio de drogas, perfazendo-se a fundada suspeita prevista no art. 240, § 1º, do CPP, e autorizando a entrada no domicílio – No mérito, pela desclassificação ao art. 28, da Lei n. 11.343/06 – Impossibilidade – Traficância presenciada pelos policiais militares – Pena devidamente fixada – Preliminar afastada e recurso desprovido.” (TJSP, Apelação nº 0007196-76.2014.8.26.0407, Osvaldo Cruz, 7ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Alberto Anderson Filho, d.j. 28/01/2016) – grifamos.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. INCIDÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE AFASTADA. INGRESSO CONSENTIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio. 2. (...)” (HC 208.957/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, 6ª Turma, d.j. 06/12/2011) – grifamos.

Afasto, pois, a preliminar arguida.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/21), laudo de constatação (fls. 83/85) e exame químico-toxicológico (fls. 88/90).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvida perante a autoridade policial, a ré declarou que estava em casa bebendo e comendo feijoada com seus familiares Antonio, o qual considera como pai, Mariluce e Fabiane, suas ex-cunhadas, e as filhas delas, quando as crianças disseram que havia um policial a chamando. Foi ao portão e os policiais a informaram de que havia uma denúncia dos vizinhos em razão de som alto e maus tratos nas crianças. Relatou que os convidados subiram para conversar com os policiais, ocasião em que estes pediram para abrir o portão. Quando entraram, afirmaram que "não era isso" e que haviam abordado um rapaz no bairro Terra Nova, o qual disse que "o restante estava lá", em uma mala preta. Ao adentrarem na residência, localizaram em um cômodo, onde costuma deixar os brinquedos das crianças, uma mala que havia sido deixada no local há duas semanas por uma pessoa de nome Rafael, o qual não sabe o endereço ou o telefone, apenas sabe que reside no Jardim Progresso. Negou saber o conteúdo da mala, alegando que preparava o jantar quando Rafael a deixou no local sem dizer o que havia dentro. A respeito das cartas encontradas, informou que são de Michel, um rapaz que foi preso por roubo e se encontra em Hortolândia. Mantinham conversas pois se relacionavam. Acrescentou que reside com seus filhos, de 10 anos, 7 anos e 2 anos, além de seu irmão, que trabalha como auxiliar de copa e cozinha na Unimed. (fls. 11/12)

Em juízo, declarou que no dia dos fatos estava no quintal de sua residência com seus familiares quando sua sobrinha lhe chamou, dizendo que havia um policial no portão. Foi até ele e soube que havia uma denúncia de maus tratos e perturbação aos vizinhos. Explicou que estava com seus familiares comendo e que nada havia acontecido, ocasião em que os policiais disseram que precisavam entrar. Falou a eles que não havia o porquê, mas diante da chegada de outros policiais, franqueou a entrada. Ato contínuo, os policiais disseram que, na verdade, se tratava de um indivíduo abordado no bairro Terra Nova que indicou a eles sua residência. Informou os policiais que não havia nada no local, então eles foram até um quarto nos fundos e localizaram uma mala. Indagada a respeito do proprietário da mala, disse que era de Rafael, que este havia se desentendido com a esposa e saído de casa, ocasião em que lhe perguntou se poderia deixar as roupas dele na sua residência, enquanto procurava um local para morar. Estava cozinhando no momento e Rafael disse que assim que encontrasse uma casa, voltaria para buscar a mala. Conhece Rafael desde a adolescência, estudaram juntos e sua mãe era amiga da mãe dele, inclusive iam juntas buscá-los na escola. Não sabe o nome completo dele, apenas que o sobrenome dele é Silva. A mãe dele se chama Odila e atualmente reside em Minas Gerais. Rafael reside no bairro Jardim Progresso. Não sabe o endereço completo deles. Depois que se mudou para o bairro Vila Nova, Rafael não costumava frequentar sua casa, apenas a ajudou com a mudança. Eram amigos. Conversavam geralmente aos finais de semana, quando Rafael lhe informava que estava com problemas no relacionamento e queria se separar. Não desconfiou do conteúdo da mala. Faria duas semanas que a mala estava em sua residência. Foi para a delegacia em seguida e lá informou que a mala era de Rafael, mas não tinha o endereço completo dele. Nunca mais o viu ou soube a respeito dele. Negou ter dito aos policiais o nome Jailson. Não conhece ninguém com esse nome. (SAJ)

A testemunha de acusação, Lucas Henrique Ferreira dos Santos, policial militar, declarou que a equipe tinha recebido uma denúncia anônima informando de que naquela tarde, na Avenida 52 A, nº 1085, bairro Vila Nova, um veículo havia deixado uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência. Diante dos fatos, a

equipe intensificou o patrulhamento no bairro, e ao passarem pelo referido endereço avistaram uma mulher na garagem da residência, identificada como Viviane. Em conversa, relatou a Viviane que obteve informações de que um veículo teria deixado uma quantidade de entorpecentes em sua residência. Ela confirmou que, de fato, haviam deixado uma mala preta em sua residência mas disse não saber a procedência e o que havia no interior da mala. Ao questionar se poderia entrar na residência e averiguar, ela cedeu a permissão na condição da vistoria ser realizada na presença do irmão dela, também morador da residência. Em um cômodo externo, foi localizada uma mala preta que continha grande quantidade de entorpecentes e apetrechos, sendo cocaína e maconha. Ao questionar novamente, a proprietária da residência sobre o material encontrado, ela negou ter conhecimento do conteúdo da mala e informou que quem havia deixado foi um amigo dela chamado Jailson. Ainda no interior da mala, foi encontrada uma bolsa de pequeno porte que continha diversas cartas abertas. Negou ter realizado diligências e constatado que Jailson estava preso. Informou que Viviane disse que teria guardado a mala como um favor para seu amigo, mas que a todo tempo negava saber do conteúdo da mala. Dentro da residência também haviam outros familiares, mas nenhum deles tinha conhecimento sobre a mala. (SAJ)

A testemunha de acusação, Josinei Rodrigues Teles, policial militar, declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento quando recebeu a informação de que um veículo VW/FOX, preto, havia deixado uma mala, possivelmente com entorpecentes, em uma residência no bairro Vila Nova. Iniciou o patrulhamento pelo bairro e quando passou na frente da residência mencionada na denúncia, avistou Viviane na garagem e a abordou. Ao questioná-la sobre a denúncia, ela confirmou que teria recebido a bolsa, mas de forma espantosa, alegou que não tinha ciência sobre o conteúdo dessa mala. De forma cooperativa ela autorizou a entrada das autoridades em sua residência e o irmão dela acompanhou a vistoria. Encontraram em um cômodo a mala, contendo grande quantidade de entorpecente, sendo 25 quilos de maconha, cocaína, e apetrechos. Posteriormente também foi localizado no interior da mala uma bolsa de pequeno porte contendo cartas abertas as quais também foram apresentadas na delegacia. A respeito do Jailson, respondeu que a Viviane mencionou que ele era um amigo de infância e que ela havia guardado a bolsa como um favor. Negou que Viviane já era conhecida no meio policial e que particularmente também não a conhecia. Informou que na residência também haviam familiares e amigos, mas que não foi feito contato com eles para não expor Viviane. Relatou que recebeu a denúncia nesse mesmo dia, enquanto realizava uma abordagem no bairro Progresso, o denunciante não quis se identificar. A respeito das cartas, informou que eram cartas destinada à Viviane, já estavam abertas e sua origem era de penitenciária. (SAJ)

A testemunha de defesa, Antônio Ferreira Ramos, declarou que é amigo de grande vínculo de Viviane. Relatou que na data dos fatos ele estava na casa da acusada, chegou por volta das 11 horas. Negou que durante o tempo em que esteve no local tenha chegado um veículo preto chamando por Viviane. Negou conhecer a pessoa de nome Jailson. Afirmou não ter conhecimento de qualquer fato que desabone Viviane, como envolvimento com drogas e tráfico. Na data em questão, Viviane não havia informado nada a respeito da mala encontrada. Informou que na época dos fatos Viviane havia saído há poucos meses da empresa em que ela trabalhava. (SAJ)

Da análise do conjunto probatório, reputo que a ré praticou o delito de tráfico de drogas.

Como se vê, a versão apresentada pela acusada não passa de tentativa de desqualificar os relatos prestados pelos policiais militares, de modo que sua alegação de desconhecimento do conteúdo da mala que se encontrava em sua residência não tem o condão de eximi-la da sua responsabilidade penal, ainda mais quando desacompanhada de provas.

Sucumbe a ré às demais provas coligadas aos autos, que dão conta de seu envolvimento com o tráfico, pois os relatos dos policiais militares são seguros

nesse sentido, estando tudo a revelar que Viviane consentiu que seu imóvel fosse utilizado para guardar os entorpecentes, de modo que não se vislumbra que os policiais tivessem inventado isso apenas para prejudicar inocente.

Veja-se a ré não arrolou no processo o suposto proprietário da mala que estava guardando nem soube indicar o nome completo ou outros dados qualificativos desse suposto indivíduo, também deixou de apresentar qualquer outra prova que sustentasse a alegação defensiva de desconhecimento acerca do conteúdo da mala, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

De outro lado, os policiais militares, em seus depoimentos, foram harmônicos ao relatarem o encontro das drogas. Disseram que receberam uma denúncia anônima informando que um veículo havia deixado uma grande quantidade de entorpecentes em uma residência. Deslocaram-se até o endereço e avistaram Viviane na garagem da residência. Em contato com ela, esta informou que haviam deixado uma mala preta em sua residência, mas que não sabia a procedência nem o que havia em seu interior. Foi franqueada por ela a entrada na residência, ocasião em que foi localizada uma mala preta contendo em seu interior os entorpecentes (cocaína e maconha) e apetrechos.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente a ré, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, por se tratar de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 – grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 -

grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

Assim, não restam dúvidas de que a acusada praticou o delito de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, incorrendo, mais precisamente, na modalidade de "guardar ou manter em depósito" substância entorpecente.

No mais, a quantidade (374 porções de cocaína em eppendorfs, com peso líquido de aproximadamente 297g, 4 porções de cocaína em papélotes, com peso líquido de aproximadamente 197g e 26 tijolos de maconha, com peso líquido de aproximadamente 21.149g), a diversidade (maconha e cocaína) e o modo em que as drogas foram apreendidas revelam que a destinação era para o tráfico.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização de Viviane pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é medida de rigor.

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena da ré.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base da ré acima do mínimo legal, tendo em vista a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, que autoriza essa exasperação. Assim, aumento sua pena inicial em 1/6, de modo que essa será de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, observo a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A ré é primária, possui bons antecedentes e não há notícias nos autos de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. No entanto, a redução da pena deverá se operar em 1/2, tendo em vista que a grande quantidade e diversidade de drogas recomendam maior rigor na aplicação desse privilégio, de maneira que a pena passará a 02 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa.

O reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, denominada “tráfico privilegiado”, traz novas consequências aos réus condenados pela prática dessa modalidade de crime, diante do recente entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula 512 do STJ, editada em 11 de junho de 2014, após o julgamento do REsp 1.329.088/RS - de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, dispunha que “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

Ocorre que, em sessão realizada no dia 23/06/2016, o Plenário do STF, por maioria de votos, no Habeas Corpus nº 118.533-MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.

Conforme esposado pela Ministra Relatora do acórdão, Cármen Lúcia, somente as figuras delitivas definidas no artigo 33, “caput” e §1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, considerando que o delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”.

Embora o referido julgamento proferido pelo Pleno do STF não tenha efeito vinculante nem eficácia erga omnes, a Terceira Seção do STJ acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo e decidiu revisar o entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.329.088/RS - Tema 600, cancelando o enunciado da Súmula 512, em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, conforme segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização

criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça." (STJ, Pet 11.796-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, d.j. 23/11/2016)

Nesse sentido, já decidiu o C. TJSP:

"Habeas corpus. Pedido de progressão de regime. Suspensão do feito pelo Juízo das Execuções, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC. Superior Tribunal de Justiça que julgou questão de ordem, cancelou a súmula nº 512 e firmou entendimento de que o tráfico privilegiado não mais é classificado como crime hediondo. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida." (HC 2241449-61.2016.8.26.0000, Des. Rel. Luiz Fernando Vaggione, Bauru, 2ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 19/12/2016)

Destarte, não há mais óbice à fixação de regime prisional diverso do fechado para os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tampouco à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou à suspensão da execução desta.

No presente caso, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não favorecem a ré, diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, e considerando a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade desta proibição pela referida Corte de Justiça na apreciação do Habeas Corpus nº 97.256/RS, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e prestação pecuniária equivalente a dois salários mínimos a ser revertida para entidade de caráter social.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra VIVIANE ANTUNES CARDOSO para CONDENÁ-LA às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e a prestação pecuniária equivalente a dois salários mínimos.

A ré terá o direito de apelar em liberdade.

Determino a destruição das drogas, caso ainda não tenha sido feita. Autorizo, ainda, a destruição dos objetos apreendidos e não reclamados.

Custas "ex lege".

P.I.

Rio Claro, 30 de maio de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA